

1515281-48.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... do réu WELLINGTON pelo delito de tráfico e a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico. Quanto à pena, manifestou-se pelo não cabimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. No mais, com relação ao réu VINICIUS, postulou a absolvição por insuficiência de provas em relação a ambos os delitos.

A defesa do réu VINICIUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515281-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515281-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Réu:

VINICIUS HENRIQUE ALVES ELOI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

VINÍCIUS HENRIQUE ALVES ELÓI (RG. 47796262/SP) e WELLINGTON AGUINALDO DE FRANÇA (RG. 38223059/SP) foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e § 1º, inciso I, c.c. artigo 40, inciso IV; e no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Conforme consta da denúncia, desde data anterior ignorada até o dia 4 de julho de 2022, nesta cidade e Comarca de São Paulo, VINÍCIUS HENRIQUE ALVES ELÓI e WELLINGTON AGUINALDO DE FRANÇA associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, crime este praticado com emprego de revólver JNA, calibre 32 e com numeração suprimida, com 13 munições no tambor e fora dele.

Consta, também, que no dia 4 de julho de 2022, por volta das 14 horas, na residência situada na Avenida Sapucaia do Sul, nº 76, Vila Renato, nesta cidade e Comarca de São Paulo, VINÍCIUS HENRIQUE ALVES ELÓI e WELLINGTON AGUINALDO DE FRANÇA, agindo com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços, preparavam, tinham em depósito e trazia com ele (WELLINGTON), ao todo, 3324 porções de tetrahydrocannabinol (maconha), com peso líquido de 12.617,1 g (doze mil, seiscentos e dezessete gramas e um decigrama); 518 eppendorf's de cocaína, com peso líquido de 263,4 g (duzentos e sessenta e três gramas e quatro decigramas); 7 tabletes de tetrahydrocannabinol (maconha), com peso líquido de 1.635,8 g (um mil, seiscentos e trinta e cinco gramas e oito decigramas); 1209

porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 266 g (duzentos e sessenta e seis gramas); 6 porções de tetrahydrocannabinol (haxixe), com peso líquido de 2,4 g (dois gramas e quatro decigramas); 4 potes plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso líquido de 1.656,3 g (um mil, seiscentos e cinquenta e seis gramas e três decigramas); um saco contendo pedras de cocaína na forma de crack a granel, com peso líquido de 1.685,1 g (um mil, seiscentos e oitenta e cinco gramas e um decigrama); um saco contendo centenas de vidros com resquícios de tricloroetileno (lança perfume), com volume líquido de 800 ml (oitocentos mililitros); e três pedras médias de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 287,9 g (duzentos e oitenta e sete gramas e nove decigramas), drogas e insumo, para fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, crime este praticado com emprego de revólver JNA, calibre 32 e com numeração suprimida, com 13 munições no tambor e fora dele, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), fotografia (fls. 20) e laudo de constatação (fls. 23/29).

Segundo restou apurado, ambos os denunciados são vizinhos, frequentam a casa um do outro e WELLINGTON teve um filho com uma falecida tia de VINÍCIUS. Ademais, ambos já ostentam condenação pretérita pelo crime de tráfico de drogas e por porte ou posse de arma de fogo, conforme certidões de fls. 60/64.

Haja vista referida intimidade, o quase laço de parentesco por afinidade e o passado criminoso idêntico em comum, os denunciados, desde data ignorada anterior até a data dos fatos, associaram-se para o fim de voltar a praticar o crime de tráfico de drogas.

Assim, na residência situada na Avenida Sapucaia do Sul, nº 76, Vila Renato, nesta cidade e Comarca de São Paulo, WELLINGTON e VINÍCIUS passaram a se dedicar a fracionar e a embalar diversos tipos de entorpecente, sendo que para proteção do local mantinham em depósito também ali o citado revólver JNA, calibre 32 e com numeração suprimida, com 13 munições no tambor e fora dele.

Os fatos somente vieram à tona porque policiais civis, de posse de informação privilegiada, deslocaram-se até o local na data dos fatos e ficaram acampanados em viatura descaracterizada, aguardando alguém chegar ou sair do imóvel.

Em dado momento, os policiais avistaram WELLINGTON entrando na casa com uma sacola. Rapidamente os policiais desembarcaram e conseguiram deter WELLINGTON, sendo que outros policiais rapidamente ingressaram no imóvel e viram o momento em que VINÍCIUS fugia pela janela, sendo, conduzido, alcançado e detido em seguida, já fora do imóvel.

Na residência, bem como no saco que WELLINGTON portava, foram apreendidos, ao todo, 3324 porções de maconha, 518 eppendorf's de cocaína, 7 tabletes de maconha, 1209 porções de crack, 6 porções de haxixe, 4 potes plásticos contendo crack, um saco contendo pedras de crack a granel, um saco contendo centenas de vidros com resquícios de tricloroetileno (lança-perfume) e três pedras médias de crack, totalizando mais de 18 kg de entorpecente e quase um litro de insumo.

Também foram apreendidos 38 comprimidos, possivelmente de (ecstasy), com peso líquido de 14,3 g (catorze gramas e três decigramas); e 112 porções, possivelmente de tetrahydrocannabinol (K2), com peso líquido de 31,1 g (trinta e um gramas e um decigrama), pendentes de análise através do laudo de exame químico toxicológico.

Ademais, foram apreendidos no imóvel, com sujidades de cocaína, quatro balanças de precisão, três potes plásticos, duas tesouras, uma colher, duas marretas e quatro assadeiras, além de 20 sacos contendo diversos saquinhos para embalar drogas.

Por fim, o revólver e a munição acima citados também restaram localizados no imóvel e apreendidos pelos policiais.

Formalmente interrogados, WELLINGTON confessou a autoria delitiva, mas buscou inocentar VINÍCIUS. Disse que, sozinho, era responsável por cortar e embalar drogas que iriam abastecer as biqueiras e que o revólver era utilizado para proteger o imóvel.

Já VINÍCIUS, ao ser formalmente interrogado, negou a autoria delitiva, dizendo que ali se encontrava para visitar um parente e que resolveu pular a janela da casa e fugir porque ficou assustado!

Em 09 de agosto de 2022, foi determinada a notificação dos acusados e, na mesma oportunidade, foi autorizada a quebra do sigilo telemático dos celulares apreendidos (fls. 211/213).

Os acusados foram notificados (fls. 23 e 232). Defesas prévias (fls. 225/228 e 238). Em 16 de setembro de 2022, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva imposta aos acusados foi mantida (fls. 249/251).

Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 257/260).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do réu WELLINGTON pelo delito de tráfico e a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico. Quanto à pena, manifestou-se pelo não cabimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. No mais, com relação ao réu VINICIUS, postulou a absolvição por insuficiência de provas em relação a ambos os delitos.

A defesa do réu VINICIUS postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas, reiterando a manifestação ministerial.

Já a defesa do réu WELLINGTON postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, fixação de pena no mínimo, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos réus VINICIUS e WELLINGTON pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, definidos no artigo 33, caput, e § 1º, inciso I, c.c. artigo 40, inciso IV; e no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos das partes.

I) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Neste ponto, a denúncia merece prosperar apenas em relação ao réu WELLINGTON. Senão vejamos:

É inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos.

A materialidade do delito resultou provada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/16), testemunhos (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), fotografia (fls. 20), laudo pericial da arma de fogo apreendida (fls. 265/271), laudo de constatação (fls. 23/29) e laudo químico-toxicológico (fls. 304/308), que constatou que os materiais apreendidos continham substâncias entorpecentes (THC, cocaína, MDMA, ADB Butinaca e tricloroetileno), inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria de WELLINGTON, apesar dos argumentos da nobre defesa.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: a campana efetuada pela Polícia Civil; a exorbitante quantidade e variedade de drogas, algumas já prontas para a venda; os apetrechos utilizados para medição, corte e embalagem de drogas; a confissão de WELLINGTON; bem como as demais peculiaridades do flagrante não autorizam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam sob a guarda do réu e destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, não sendo o caso de absolvição.

De outro lado, conforme delineado nas provas colhidas em juízo, o mesmo não pode ser dito em relação ao réu VINICIUS. Ele não foi visto no interior da casa onde estavam armazenados os entorpecentes ou na posse das drogas, bem como negou a imputação em todos os momentos em que foi ouvido, apresentando versão que não foi afastada pelo conjunto probatório.

Durante o interrogatório policial, o réu VINICIUS negou a autoria delitiva, dizendo que ali se encontrava para visitar um parente e que resolveu pular a janela da casa e fugir porque ficou assustado (fls. 07).

De outro lado, durante o interrogatório policial, o réu WELLINGTON confessou a autoria delitiva, bem como inocentou VINICIUS. Disse que, sozinho, era responsável por cortar e embalar drogas que iriam abastecer as biqueiras e que o revólver era utilizado para proteger o imóvel (fls. 08/09).

Em Juízo, o réu VINICIUS alegou que o correu tem um filho com uma tia falecida do depoente. O WELLINGTON é seu tio por afinidade. O depoente se relaciona com o depoente. O filho do Wellington tem outra opção sexual e está sofrendo preconceito na escola. Diante disso, falou com sua avó, para o menino ir morar com ela em Brasília. Foi no local para conversar com ele sobre isso. Parou para conversar com a vizinha, no quintal. O corréu pediu para esperar e ficou esperando. Nisso viu WELLINGTON correndo e um homem correndo atrás. Correu para dentro da casa e pulou a janela ao cair nos fundos. Foi parado pelo policial e se rendeu. Quando chegou ao local, ficou esperando do lado de fora. Somente entrou na casa correndo, quando viu o tumulto e o homem dizendo: "Para que vou atirar". Mora ali perto, na mesma rua. Em Juízo, o réu WELLINGTON alegou que guardava as coisas em sua casa já fazia um mês. Ganhava mil reais para guardar. O combinado era somente drogas. Eram separados por bolsas de várias cores. Eles passavam na segunda e na quinta para pegar as bolsas e avisavam com antecedência. O combinado era não mexer dentro. Não sabia da arma. no dia dos fatos, o rapaz ligou para entregar a bolsa branca. Saiu com a bolsa e, no mesmo momento, o Vinicius chegou. Ele não sabia das drogas e não se beneficiava do aluguel. Mandou Vinicius correr, para ele sair da situação, pois sabia que ele já tinha passagens anteriores. Ele trabalha normalmente. Tem passagens por tráfico e porte de armas.

Tem-se, portanto, que o réu VINICIUS tornou a negar os fatos, esclarecendo o motivo pelo qual estava no quintal da casa do corréu, ao passo que WELLINGTON ratificou sua confissão.

Com relação à confissão do réu WELLINGTON, anoto que, decididamente, a confissão judicial torna incontroversa a autoria delitiva, mormente porque corroborada pelo restante da prova.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a confissão judicial realizada espontaneamente pelo réu, ainda que seja o único elemento incriminador, é o suficiente para autorizar o decreto condenatório, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que comprovem sua falsidade ou algum vício de consentimento. Com efeito, tal confissão, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, possui valor absoluto, servindo como base condenatória. Ou seja, havendo confissão judicial, presumindo-se livremente feita, não demonstrada sua eventual falsidade por prova idônea, cujo ônus probatório incumbe ao confitente e sua defesa, só ela já basta e serve como alicerce para o decreto condenatório.

Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos das testemunhas arroladas.

De outro lado, entendo que a versão exculpatória apresentada pelo réu VINICIUS não pode ser descartada, especialmente diante da frágil prova produzida nos autos acerca de seu envolvimento com as drogas.

Neste aspecto, restou demonstrado que VINICIUS não residia e nem era responsável pelo imóvel onde estavam as drogas, foi surpreendido pelo policial do lado de fora do imóvel e somente correu ao perceber o tumulto. Outrossim, negou em todos os momentos em que foi ouvido envolvimento com as drogas, versão confirmada pelo réu confesso.

Os agentes da lei, ao contrário do firmado pela defesa de WELLINGTON, narraram os fatos de maneira convicta, restando claro que narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos, incluindo a conduta individualizada do réu no momento do crime.

Os relatos dos policiais foram firmes, coerentes e detalhados.

Assim, a testemunha ANDRE, policial civil, em Juízo, reconheceu os réus e narrou que receberam a denúncia de que no endereço em questão eram armazenadas drogas.

Fizeram uma campana no local e num determinado momento o réu WELLINGTON saiu do imóvel com uma bolsa térmica branca nas mãos. Ele ficou aguardando e num determinado momento caminhou e notou a viatura descaracterizada. Ele suspeitou e fez menção de retornar para o imóvel. O depoente desceu e anunciou que era a polícia. Ele correu para dentro do imóvel, momento em que o depoente reparou no Vinicius no quintal e, ao ver o tumulto, correu para os fundos. O depoente deteve o Wellington e o parceiro, com apoio de outra viatura, deteve o Vinicius na rua de trás. Na bolsa branca, dois pacotes grandes de crack. Dentro do imóvel, aparentemente uma residência, encontraram atrás de um sofá. Elas estavam num saco com facas, utensílios e uma arma. Havia uns panos em cima. O odor de maconha era forte. O Wellington assumiu a posse das drogas. O Vinicius alegou que estava ali apenas para visitar os parentes.

A testemunha JOÃO CARLOS, policial civil, em Juízo, reconheceu os dois réus e declarou que estavam na região e quando entraram na via dos fatos, viram a movimentação de policiais civis e prestaram apoio. O parceiro logrou abordar um dos réus. Não recorda qual deles. Ficou fazendo a segurança. Não presenciou a localização das drogas.

A testemunha MAURICIO, policial civil, em Juízo, reconheceu os réus e narrou que durante o patrulhamento viram a movimentação de policiais do DENARC. Firam os policiais correndo. Foram para os fundos do imóvel e deram apoio as policiais do Denarc. Quando chegou ao local, viu o rapaz andando dentro do córrego. Outros policiais que abordaram o VINICIUS.

A testemunha EMERSON, policial civil, em Juízo, reconheceu os dois réus e declarou que receberam a denúncia de que no endereço em questão poderiam estar armazenando drogas. Fizeram uma campana no local e num determinado momento o réu WELLINGTON saindo do imóvel com uma bolsa térmica branca nas mãos. Ele ficou aguardando e num determinado momento caminhou e notou a viatura descaracterizada. Ele suspeitou e fez menção de retornar para o imóvel em passos largos. O parceiro logrou deter o rapaz e o parceiro avisou que outro havia corrido para dentro da casa. Foi atrás e entrou na casa, subiu a escada e deparou com a janela aberta. Uma viatura deu apoio e logrou deter o réu VINICIUS na rua de trás. O VINICIUS disse que não tinha relação com a casa e estava visitando parentes no local. Quando desceu a escada viu os sacos ao lado do sofá. Dentro da casa era possível sentir o odor das drogas. Havia maconha, crack, cocaína, balança, faca, colher, arma de fogo. Estava tudo junto nos sacos. Não sabe da versão dada por WELLINGTON. O VINICIUS disse que correu porque ficou assustado com o correu correndo e uma pessoa atrás dele. Não viu perfeitamente o réu subindo a escada e pulando a janela, mas viu o Vinicius na rua caído com o pé machucado. Depois que tudo se acalmou, o WELLINGTON assumiu que a droga era toda dele, bem como que VINICIUS não tinha envolvimento com as drogas. WELLINGTON disse que VINICIUS era um parente dele. Estavam com uma viatura descaracterizada e estavam identificados com distintivos.

Verifico que os policiais narraram de maneira uníssona que, através de informações privilegiadas, dirigiram-se ao local dos fatos e efetuaram campana. Em certo momento, o réu WELLINGTON foi avistado adentrando o imóvel com uma sacola em mãos. Abordado, dentro da sacola foram localizadas drogas. Os policiais que se aproximaram da residência visualizaram o réu VINICIUS no quintal, momento em que empreendeu fuga, mas foi detido. Pela casa, foram localizadas diversas porções de tipos variados de drogas, além de petrechos destinados ao preparo para a mercancia ilícita.

Apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos policiaes é digna de fé. Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade de seus depoimentos, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: "PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câ. - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Anoto que, apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos policiais é digna de fé. Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha. Nesse sentido: "PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câm. - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Neste aspecto, vale atentar que não tem cabimento imaginar que a polícia teria a possibilidade de deter traficantes e, deliberadamente, imputar aos réus a responsabilidade sobre o entorpecente, apenas e tão somente para prejudicá-los. Os policiais não teriam motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicar os acusados, que sequer conheciam até aquela data.

No mais, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os agentes policiais não estão proibidos de depor nos processos de cuja fase extrajudicial participaram. De outro lado, não foram arroladas testemunhas ou apresentadas provas aptas a macular os depoimentos dos policiais.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu WELLINGTON, sendo de rigor a absolvição de VINICIUS, por todo o acima exposto. Senão vejamos:

WELLINGTON, agindo com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços com terceiros tinha em depósito e trazia com ele, ao todo, 3324 porções de maconha, 518 eppendorf's de cocaína, 7 tabletes de maconha, 1209 porções de crack, 6 porções de haxixe, 4 potes plásticos contendo crack, um saco contendo pedras de crack a granel, um saco contendo centenas de vidros com resquícios de tricloroetileno (lança-perfume) e três pedras médias de crack, totalizando mais de 18 kg de entorpecente e quase um litro de insumo. No imóvel também foram apreendidos, com sujidades de cocaína, quatro balanças de precisão, três potes plásticos, duas tesouras, uma colher, duas marretas e quatro assadeiras, além de 20 sacos contendo diversos saquinhos para embalar drogas. Por fim, o revólver e a munição acima citados também restaram localizados no imóvel e apreendidos pelos policiais.

Sendo assim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar o réu como traficante, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidos.

É de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, pois o tráfico de drogas ora tratado envolveu a apreensão do revólver JNA, calibre 32 e com numeração suprimida, com 13 munições no tambor e fora dele. O exame pericial balístico atestou a eficácia da arma de fogo e das munições, conforme fls. 265/271.

Por fim, atentando-se à quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como à reprovável vida criminal pregressa do réu, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Desta feita, não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, é de rigor a condenação do réu WELLINGTON pelo delito previsto no artigo 33, caput, e § 1º, inciso I, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

II) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Razão assiste às defesas quanto ao pleito de absolvição pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, pois não se vislumbra, no caso em exame, a presença dos requisitos do crime de associação para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de entorpecente, especialmente devido a falta de provas em relação a

efetiva participação de VINICIUS no tráfico.

Ora, ainda que possível a hipótese de associação entre o réu e terceiros, não há nos autos provas contundentes necessárias a embasar uma condenação por um delito de tamanha gravidade, sendo que a prudência aqui recomenda a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A propósito, dispõe o referido artigo: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo primeiro, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa".

Com efeito, são pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei nº 11.343/06, com dolo específico ou elemento subjetivo do tipo, não havendo, entretanto, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente, para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal. Ausente um destes requisitos, resta configurada a associação momentânea, regulada na lei penal como concurso de pessoas, tratando-se de uma causa especial de aumento da pena e não um delito autônomo.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos de sua definição. Neste sentido preleciona Vicente Greco Filho: "Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..." (GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei nº 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei nº 6.368/76 - 12ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

Portanto, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

Na espécie, inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não há como reconhecer, in casu, o delito de associação, pois meros indícios ou presunções não são suficientes para esse mister, notadamente no que diz respeito ao animus associativo, que por ser figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, deve restar indubitavelmente comprovado, já que o simples concurso não é o bastante para essa finalidade.

Sobre o assunto trago à colação os seguintes julgados: "Crime de associação - Concurso ocasional de agentes - Delito não-configurado - Inteligência do artigo 14 da Lei nº 6.368. de 1976. A associação de que trata o artigo 14 da Lei nº 6.368, de 1976, é a reunião mais ou menos estável ou permanente, para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal. Insuficiente a tal desiderato é o simples concurso de agentes, pena de se erigir em delito autônomo a simples co-participação criminosa." (Ac. un. 5ª Câmara de Criminal; apud GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção - Repressão: Comentários à Lei nº 10.409/2002 e à parte em vigor da Lei nº 6.368/76 - 12ª ed. Atual. - São Paulo - Editora Saraiva - 2006 - p. 127).

"TÓXICOS - TRÁFICO - ASSOCIAÇÃO - CONCURSO DE AGENTES - INOCORRÊNCIA - PROVA INSUFICIENTE - DEPOIMENTOS SUSPEITOS DE POLICIAIS - RECEPÇÃO DOLOSA - AGENTE QUE ARREBATA, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, BEM MÓVEL DE OUTREM COMO RESSARCIMENTO PELA VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - DELITO DESCARACTERIZADO. Não

há falar no crime autônomo de associação (Art. 14 da Lei nº 6.368/76) se os elementos de convicção coligidos nos autos não demonstram com a indispensável segurança a existência, entre os agentes, de um 'animus' associativo, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma 'societas sceleris' à prática do crime visado. (...)." (TJMG, 1ª C.Crim., APCR nº 1.0024.04.383774-9/001, Rel. Des. Gudestev Biber, v.u. julg. 18.10.2005; pub. no DOMG de 26.10.2005).

Restando, pois, improvable o animus associativo mais ou menos estável ou permanente, não há que se falar em associação para o tráfico, pois, para a sua caracterização é indispensável a associação de duas ou mais pessoas; acordo dos parceiros; vínculo associativo; e a finalidade de traficar tóxicos, formando uma verdadeira societas sceleris para essa finalidade.

De rigor, portanto, a absolvição dos réus pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

Verifico que a imensa quantidade e variedade de drogas, bem como a apreensão de diversos petrechos destinados para a preparação dos entorpecentes à venda ilícita, ensejam maior reprimenda à conduta perpetrada pelos acusados, os quais eram responsáveis por todo um imóvel destinado a abastecer o tráfico de drogas da região. Assim, considerando ainda que o réu WELLINGTON ostenta maus antecedentes (fls. 60/61), a pena será fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 666 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. Na segunda fase, verifico que WELLINGTON é tecnicamente primário, não havendo circunstâncias agravantes a serem consideradas. De outro lado, há a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 555 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Na terceira fase, incide somente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Assim, majoro as penas em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 647 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE) DIAS-MULTA.

Quanto às penas de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência:

I - ABSOLVO o réu VINÍCIUS HENRIQUE ALVES ELÓI (RG. 47796262/SP), qualificado nos autos, das sanções do artigo 33, caput, e § 1º, inciso I, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II - CONDENO o réu WELLINGTON AGUINALDO DE FRANÇA (RG. 38223059/SP), qualificado nos autos, à pena de 06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 647 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE) DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, e § 1º, inciso I, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

III) ABSOLVO os réus VINÍCIUS HENRIQUE ALVES ELÓI (RG. 47796262/SP) e WELLINGTON AGUINALDO DE FRANÇA (RG. 38223059/SP), qualificados nos autos, das sanções previstas no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou conceder o sursis penal, pois ausentes os requisitos legais.

Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, dos maus antecedentes do réu WELLINGTON e da quantidade das penas, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser feito em regime prisional inicial FECHADO, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou agressão ao princípio da individualização da pena, mormente porque permitida a progressão de regime.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução e, não havendo alterações fáticas que demonstrem a ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar, não faculto a ele a oportunidade de recorrer em liberdade.

Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento em nome do acusado WELLINGTON,

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal competente.

Considerando a absolvição de VINICIUS, expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Quanto aos itens apreendidos, autorizo a incineração das drogas e a destruições dos objetos apreendidos. Oficie-se.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA